

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-2]권고조치를 대상으로 한 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 폐기물 관리법 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 소송요건으로서 어떠한 의미를 갖는지 기술하고, 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 내려야 하는 판결의 종류와 그 사유를 설명하라.》

<문제2.1의 물음2> 권고조치 대상 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청의 처분이 아닌 사실상의 행정지도인 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이때 <乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 어떠한 법적 의미를 갖는지> 검토가 필요하다. 또한 <취소소송의 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 어떠한 판결을 내려야 하는지>와 그 사유를 명확히 규명해야 한다. 이하에서는 대상적격의 의의와 소송요건 흠결 시의 판결인 각하판결에 대해 설명한다.

II. 대상적격의 의미와 乙의 소송에서의 중요성

1. 대상적격의 의의

- 대상적격이란 행정소송의 대상이 될 수 있는 적절한 자격을 의미한다. 행정소송법 제2조 제1항 제1호 및 제19조에 따라 취소소송의 대상은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용인 처분등이어야 한다.

2. 乙의 소송에서 대상적격의 의미

(1) 소송의 적법성 판단 기준

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 원칙적으로 행정지도에 해당한다. 행정지도는 상대방의 임의적 협력을 전제로 하는 비권력적 사실행위로서, 국민의 권리와 의무에 직접적인 법적 변화를 일으키지 않으므로 처분성이 부정되는 것이 원칙이다. 따라서 乙의 소송에서 대상적격의 존부는 해당 소송이 본안 심리로 나아갈 수 있는지 여부를 결정하는 핵심적인 관문이 된다.

(2) 항고소송의 범위 확정

- 대상적격은 사법권에 의한 행정통제의 범위를 확정하는 기능을 한다. 권고 조치가 예외적으로 처분성을 인정받지 못한다면, 이는 행정소송의 대상이 될 수 없음을 의미하며 사법부가 개입할 수 없는 영역으로 남게 된다.

III. 소송요건 결여 시의 판결 유형 : 각하판결

1. 각하판결의 의의

- 각하판결이란 소송요건이 흠결되어 소송이 부적법한 경우, 본안(처분의 위법성 여부)에 대하여 판단하지 않고 소송을 종결시키는 판결을 말한다. 이는 소송의 개시를 거절하는 소송판결의 일종이다.

2. 각하판결의 사유

(1) 소송요건의 불비

- 취소소송이 적법하기 위해 갖추어야 할 대상적격, 원고적격, 협의의 소의, 피고적격, 제소기간, 행정심판 전치주의 등의 요건 중 어느 하나라도 결여된 경우이다. 사안의 乙처럼 처분성이 없는 행정지도를 대상으로 소를 제기한 경우 대상적격 흠결이 각하 사유가 된다.

(2) 보정의 불가능 또는 불이행

- 흠결된 소송요건이 보정할 수 없는 것이거나, 법원의 보정 명령에도 불구하고 원고가 이를 보정하지 않은 경우 법원은 각하판결을 내린다. 행정지도를 대상으로 한 소송은 처분성이라는 본질적 요건의 흠결로 보정이 불가능한 경우가 많다.

IV. 사안의 적용

1. 乙이 제기하려는 소송의 대상적격 검토

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 사례에서 사실상의 행정지도에 불과한 것으로 명시되어 있다. 판례에 따르면 행정지도는 공권력의 행사가 아니므로 취소소송의 대상인 처분에 해당하지 않는다. 따라서 乙의 소송은 대상적격이라는 소송요건을 결여하고 있다.

2. 법원이 내려야 하는 판결 : 각하판결

- 법원은 乙이 제기한 소송을 심리함에 있어 직권조사 사항인 대상적격 유무를 먼저 확인해야 한다. 조사 결과 권고 조치의 처분성이 부정되므로, 법원은 본안 심리인 영업상 손실의 위법성 여부를 판단할 필요 없이 소송법적 판단만으로 소를 각하해야 한다.

3. 각하판결의 사유

- 乙의 소송은 행정소송법 제2조 및 제19조가 정한 처분을 대상으로 하지 않았으므로 대상적격을 갖추지 못하였다. 이러한 소송요건의 흠결은 강행규정 위반으로 부적법한 소 제기해 해당하며, 사법 자원의 효율적 배분과 행정권의 독립성 존중을 위해 법원은 각하판결로써 소송을 종결시켜야 한다.

V. 결론

- 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격은 소의 적법성을 결정짓는 필수적인 소송요건이다. 행정지도에 불과한 권고 조치는 처분성이 부정되므로 乙의 소송은 대상적격을 결여한 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이러한 소송요건의 흠결을 이유로 본안 판단을 거절하는 각하판결을 내려야 한다. 이러한 법리는 국민의 권리구제와 행정작용의 처분성 사이의 한계를 명확히 함으로써 행정소송의 적법한 범위를 확정하는 데 기여한다.